

1500099-25.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... e, por isso, sobrevivia do tráfico. Asseveraram que, na delegacia, encontraram, com o acusado, mais 150 reais, em três notas de 50, as quais ele revelou que eram proveniente da venda de drogas. Disseram que ele já era conhecido pela prática de tráfico e que o caderno do hotel mencionava que o acusado estava sozinho no quarto. Os depoimentos prestados por agentes são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500099-25.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500099-25.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2019688/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 15811818 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 938/21/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 946/21/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2019688 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 938/21/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 946/21/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA SILVA SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Lucas da Silva Souza, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 22 de janeiro de 2021, a 1h15min, na Praça Machado de Melo, 116, Vila Guaggio, nesta cidade de Bauru-SP, o acusado teve em depósito, para o tráfico ilícito, 3,03 gramas de crack repartidos em 16 porções, 6,33 gramas de maconha divididos em 6 porções e 0,93 grama de cocaína repartidos em 3 porções,

substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletins de ocorrência (fls. 10/15), auto de exibição/apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação preliminar (fls. 19/24) e laudo definitivo (fls. 95/97).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise da formalidade do ato (fls. 74/79), foi o acusado posto em liberdade com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Foi ofertada proposta de ANPP (fls. 101/107), contudo, ante a não localização do acusado, foi cancelada a audiência onde o acordo poderia ser firmado (fls. 115/116).

Pela decisão de fls. 120/129 foi recebida a denúncia, determinada a notificação e citação e decretada a prisão preventiva do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 162), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 167).

Na decisão de fls. 172/173, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 226/228 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 233/240 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, com a valoração da personalidade transviada (em razão dos feitos da seara infracional), o reconhecimento da agravante do “estado pandêmico” e da atenuante da menoridade relativa, com o afastamento do “tráfico-privilegiado” e a fixação do regime inicial fechado.

Já a D. Defesa, às fls. 243/264 pleiteou, em síntese, a nulidade da prova colhida com violação de domicílio, ou a desclassificação para o delito consumo pessoal, a valoração da menoridade relativa, o afastamento da agravante do “estado pandêmico”, a constatação da aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime menos gravoso.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De início, de rigor a análise da preliminar de eventual nulidade, em razão da suposto ingresso sem autorização do acusado.

Na fase policial, os milicianos citaram que o acusado franqueou a entrada (fls. 06/07).

No interrogatório policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 08).

Depois, o acusado, recusou-se a fornecer os dados de pregressamento (fls. 39).

Não há nulidade, até porque houve “denúncia anônima” pretérita de que no hotel um hóspede comercializava entorpecentes no interior de seu quarto, aposento o qual, diga-se não há qualquer comprovação que era utilizado como moradia perene.

Assim, mesmo antes da ida até o domicílio, havia fundadas razões da ocorrência do tráfico, pois o acusado já portava a droga.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CRIME – FLAGRANTE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, surge lícita a entrada forçada em domicílio sem prévia autorização judicial. INTERROGATÓRIO – RITO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. O disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal, no tocante ao momento do interrogatório do acusado, não se aplica a processo-crime sob o rito da Lei nº 11.343/2006, ante a especialidade. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

(STF, 1ª Turma, HC 175123 / SP - SÃO PAULO, relator ministro Marco Aurélio, julgado em 11/05/2020)

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (fls. 10/15), auto de exibição/apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação preliminar (fls. 19/24) e laudo definitivo (fls. 95/97).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Rodrigo Fabiano Ortiz e Marcelo Wanderlei Barreira, na fase judicial (mídia SAJ) disseram, em resumo, que receberam a informação de populares de que, no quarto n.106 do Hotel Imperial, um dos hóspedes estaria traficando drogas. Informaram que foram até o local, onde o recepcionista os levou até o citado quarto. Afirmaram que o acusado se encontrava no quarto e autorizou a entrada da polícia. Esclareceram que, durante as revistas, acharam, em cima do guarda-roupa, uma bolsa de pano com 16 pedras de 'crack', 6 porções de maconha e 3 pinos de cocaína, além de 155 em notas e moedas. Mencionaram que, no colchão, havia 30 saquinhos de 'sacolé', usados para embalar as drogas. Citaram que ele confessou a traficância, dizendo que estava desempregado e, por isso, sobrevivia do tráfico. Asseveraram que, na delegacia, encontraram, com o acusado, mais 150 reais, em três notas de 50, as quais ele revelou que eram proveniente da venda de drogas. Disseram que ele já era conhecido pela prática de tráfico e que o caderno do hotel mencionava que o acusado estava sozinho no quarto.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela r. jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Lucas sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em síntese, negou a traficância. Disse que estava morando no hotel há duas semanas. Afirmou que a polícia foi ao local com um usuário de droga alegando que havia uma 'denúncia' de

tráfico. Informou que eles revistaram o quarto e nada encontraram. Esclareceu que, em seguida, entrou um terceiro policial que saiu instantes após dizendo que havia achado um saquinho com drogas. Mencionou que foi levado preso, enquanto seu cunhado Cristian, que também estava no quarto, acabou sendo liberado. Citou que era usuário de droga. Asseverou que, quando adolescente, ficou internado na Fundação Casa, por sete meses, por ato infracional correspondente ao crime de tráfico de drogas. Pela prova colhida, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas. De acordo com o feito, após "denúncia anônima" policiais foram até o Hotel Imperial, onde, após entrarem no quarto do acusado, localizaram, em cima do guarda-roupa, uma bolsa de pano com 16 pedras de 'crack', 6 porções de maconha e 03 pinos de cocaína, além de 155 em notas e moedas (e mais 150 reais durante os procedimentos da Delegacia).

Já, no colchão, havia 30 saquinhos - 'sacólés', usados para embalar as drogas. Por isso, a prática do delito é clara, tendo em vista que o acusado nem sequer alegou qualquer animosidade em relação aos policiais.

Depois, não é caso de desclassificação para o delito de consumo pessoal.

Ainda que não razoável a quantidade, foi apreendida variedade de entorpecentes (maconha, 'crack' e cocaína), com quantia considerável de dinheiro (R\$ 305,00), em notas diversas.

Em acréscimo, na seara infracional o acusado foi responsabilizado pelo delito de tráfico de drogas, fato, inclusive, confirmado por ele (fls. 56).

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AFIRMAÇÃO DE PORTE DA DROGA PARA USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312 DO CPP.

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE DIFERENCIADA. PERICULOSIDADE SOCIAL.

NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Mostra-se incabível concluir-se pela sustentada desnecessidade da prisão preventiva, dada a alegação de que o recorrente seria mero usuário e não traficante, em remédio constitucional, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

2. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito.

3. A variedade e a natureza altamente deletéria de parte dos entorpecentes localizados em poder do réu - cuja residência era utilizada como ponto de venda de drogas para adolescentes -, são fatores que, somados à apreensão de 9 (nove) aparelhos celulares no interior do imóvel, os quais eram trocados por estupefacientes, indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva, sobretudo quando foi reconhecido no édito condenatório, com base no acervo probatório produzido na ação penal, sua dedicação à prática de atividades ilícitas.

4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva.

5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

6. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito.

7. Recurso ordinário conhecido e improvido.

(STJ, 5ª Turma, RHC 73254 / CE, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 02/05/2017)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Sob outro aspecto, deve o acusado Lucas permanecer custodiado.

A natureza de parte entorpecente - cocaína e 'crack' - conforme adiante se verá é

perniciosa.

Ademais, o acusado possui passado, como dito, na seara da infância e juventude. Além disso, às fls. 220/221, Lucas possui condenação proferida em seu desfavor em primeira instância, feito nº 1500749-72.2021.

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, não se olvidando, ainda, que o acusado descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Réu Lucas da Silva Souza

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (cocaína e 'crack') denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto porque, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela r. jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º,

da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na segunda fase, a menoridade relativa atenua a pena em 1/6, atingindo 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentas) diárias.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. O réu possui "passado infracional", inclusive por crime análogo de tráfico de drogas, cometido há pouco, o que denota que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na variedade dos entorpecentes apreendidos - 81,5g maconha e 30,7g cocaína -, na própria confissão do agente e nos registros de atos infracionais análogos aos delitos de homicídio e de furto que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 447045 / SP, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 07/08/2018).

Portanto, no caso concreto, as medidas socioeducativas do ECA não foram suficientes para “adequar” a personalidade do adolescente, sendo, portanto, necessária a efetiva reprovação, considerando-se, ainda, o caráter equiparado a hediondo do delito em questão.

Por isso, a pena atingida, na segunda fase, é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do acusado.

Fixo o regime inicial fechado, eis que é o único apto a atender às finalidades da pena, quais sejam: preventiva e repressiva.

O réu Lucas já foi condenado em primeira instância por delito de estelionato.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita, CONDENO o réu Lucas da Silva Souza, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado Lucas o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto aos petrechos e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA